

1500925-67.2021.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GABRIEL ARAÚJO GONZALEZ

Comarca: Cachoeira Paulista

Foro: Foro de Cachoeira Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... do TJSP:

APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM.

Pretensão de reforma, quanto a cada um dos ilícitos, e substituição da reprimenda.

Parcial possibilidade. 1. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade demonstradas.

Depoimento dos policiais. Meio seguro de prova. Precedentes. 2. Associação para o

tráfico. Dolo associativo não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cachoeira Paulista

1ª Vara

Praça Prefeito Prado Filho, s/nº, ., Centro - CEP 12630-000, Fone: (12) 3101-1424,

Cachoeira Paulista-SP - E-mail: cachpta@tjsp.jus.br

1500925-67.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital n.

1500925-67.2021.8.26.0621

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALESSANDRO TAVARES DOS SANTOS e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ARAÚJO GONZALEZ

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de denúncia oferecida contra ALESSANDRO TAVARES DOS SANTOS e LUIZ GUSTAVO TAVARES DOS SANTOS pela suposta prática do crime dos s artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 e no artigo 180, caput, do Código Penal.

Na denúncia, narra-se que:

[...] O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pelo Promotor de Justiça infra-assinado, no uso e gozo de suas atribuições constitucionais e legais, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, com base no incluso auto de prisão em flagrante, oferecer DENÚNCIA em face de ALESSANDRO TAVARES DOS SANTOS, qualificado às fls. 21/22 e LUIZ GUSTAVO TAVARES DOS SANTOS, qualificado à fl. 20, pelo fato punível que passa a relatar.

Consta do incluso auto de prisão em flagrante que, no dia 17 de outubro de 2017, em horário e local incerto, ALESSANDRO TAVARES DOS SANTOS, adquiriu, recebeu e conduziu, em proveito próprio, a motocicleta Honda, placas EHI9572, Cruzeiro/SP, que sabia ser produto de crime.

Consta, ainda, que, em data incerta, porém até o dia 21 de outubro de 2021, às 15h30, na Rua Amilton Vieira Mendes, nº 410, Embauzinho, nesta cidade e Comarca de Cachoeira Paulista, ALESSANDRO TAVARES DOS SANTOS e LUIZ GUSTAVO TAVARES DOS SANTOS associaram-se para praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas.

Consta ainda que, no dia 21 de outubro de 2021, às 15h30, na Rua Amilton Vieira Mendes, nº 410, Embauzinho, nesta cidade e Comarca de Cachoeira Paulista, ALESSANDRO TAVARES DOS SANTOS e LUIZ GUSTAVO TAVARES DOS SANTOS, previamente ajustados e em unidade de desígnios, mantinham em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 03 (três) vasos, contendo Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, bem como 03 (três) porções da mesma substância, 238 (duzentas e trinta e oito) porções de cocaína pulverizada e 13 (treze) porções de cocaína petrificada - crack, tudo com massa bruta de 724,18 gramas, substâncias que causam dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, fotografias de fls. 33/45 e laudo de constatação de fls. 51/54.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias acima mencionadas, ALESSANDRO TAVARES DOS SANTOS e LUIZ GUSTAVO TAVARES DOS SANTOS, mantinham sob sua guarda, 01 (uma) munição calibre .38, de uso permitido, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13/14).

Segundo o noticiado, a motocicleta Honda, placa EHI 9572, Cruzeiro/SP foi subtraída de seu proprietário aos 14/10/2021, fato registrado no RDO 254/2021 DIG de Cruzeiro. No dia 17 de outubro, ALESSANDRO adquiriu a motocicleta, ciente de sua origem ilícita, e passou a conduzi-la em via pública.

Na data dos fatos, policiais militares em patrulhamento receberam a informação de que a motocicleta produto do roubo vinha sendo conduzida em via pública por ALESSANDRO. De posse de tais informações, os policiais dirigiram-se até sua residência.

No local, tiveram a entrada franqueada e passaram a inspecionar o imóvel.

Em revista, foram localizadas, logo na entrada da residência, 03 (três) vasos de maconha. No quarto dos denunciados, foram localizadas, em cima do armário, 02 (duas) porções de cocaína à granel, 10 (dez) pedras de crack, 231 (duzentos e trinta e um) pinos de cocaína, bem como a quantia de R\$198,00 (cento e noventa e oito reais) em notas diversas, obtida na mercancia ilícita, e três balanças digitais, com função de pesagem da droga traficada pelos denunciados.

Dando continuidade às buscas, foi localizada uma carteira em nome de LUIZ GUSTAVO e, em seu interior, foram localizadas outras 03 (três) pedras de crack e 05 (cinco) pinos de cocaína, bem como um cartucho, calibre .32 e anotações típicas da mercancia ilícita. Sob a cama, foram localizadas mais 03 (três) porções de maconha. Ao ser interrogado, ALESSANDRO confessou a traficância, bem como a aquisição da motocicleta, produto de roubo. Alegou, ainda, que dispensou a motocicleta em um matagal.

A natureza, quantidade, circunstância da apreensão da droga e a forma de acondicionamento, evidenciam que as substâncias se destinavam ao consumo de terceiro e que os denunciados estavam associados para o comércio de entorpecentes. [...]

Às fls.114/115, houve a notificação dos denunciados.

Às fls.116/120 e 141/147 foram acostados os laudos periciais.

Às fls.138/139, os réus apresentaram resposta à acusação.

Às fls.151/154, houve o recebimento da denúncia, negou-se a absolvição sumária dos Réus e foi designada audiência de instrução e julgamento.

Em 03 de outubro de 2020 à fl.198, foi realizada audiência de instrução e julgamento.

Em alegações finais, o MP pugnou pela parcial procedência da ação penal.

Em alegações finais, a defesa requereu pela absolvição dos acusados;

subsidiariamente pela desclassificação do réu Luiz Gustavo para o art.28 da lei nº 11.343/2006.

É o relatório. Passo a decidir.

II- FUNDAMENTAÇÃO

II. 1 - DA SITUAÇÃO DO RÉU LUIZ GUSTAVO TAVARES DOS SANTOS.

II. 1.1 - Do crime de tráfico de drogas

Cuidam os autos de ação penal pública que visa apurar a suposta prática do crime do art. 33 da Lei de Drogas.

Inexistindo questões preliminares e/ou prejudiciais capazes de inviabilizar a análise do mérito da causa, ou mesmo nulidades que possam macular os atos e os processos como um todo, as questões trazidas a juízo merecem um provimento jurisdicional de cunho material.

O tipo objetivo do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

Em sua oitiva em juízo, o informante LUIZ ALBERTO TAVARES DOS SANTOS afirmou que: estava hora errada; não morava lá direito/ estava dormindo no momento; deitou na cama do irmão; quando acordou, a polícia estava lá procurando a moto; a polícia entrou no quarto do Réu e avistaram tudo lá; a droga era de ALESSANDRO;

Em sua oitiva em juízo, a testemunha WALTENCIR ALVES afirmou que: a moto foi roubada em Cruzeiro; havia informações de que ela estaria no Embauzinho; no local, falaram a residência em que ela estaria; na entrada da residência, viram 3 pés de maconha cultivados no local; chamaram na casa e LUIZ atendeu e autorizou a entrada; no local, foram encontradas diversas drogas de propriedade de ALESSANDRO; encontraram porções de maconha, pedras de crack, cocaína, dinheiro; convidou LUIZ ALBERTO a ir até a delegacia; no percurso, LUIZ ALBERTO indicou um irmão (LUIZ GUSTAVO); abordaram LUIZ GUSTAVO e encontraram droga com ele; LUIZ GUSTAVO falou que era usuário; ele também foi conduzido à delegacia; durante a apresentação na delegacia, uma advogada informou que as drogas seriam de propriedade de ALESSANDRO, que iria se apresentar; depois que ALESSANDRO se apresentou, ele informou o local em que ela estava e a equipe foi até o local, mas não achou; foi lavrado o flagrante de tráfico; a moto foi encontrada dias depois..

Em sua oitiva em juízo, a testemunha JOSUÉ ELOI MOREIRA afirmou que: a moto não foi apreendida no dia; trabalha em Cruzeiro; foi levantado que essa moto estava em posse de um morador do Embauzinho; em um dia, encontraram entorpecente; no outro dia, encontraram a moto; houve um roubo em Cruzeiro; obtiveram informações de que um indivíduo estava pilotando a moto roubada em Cruzeiro; informações chegaram de que essa moto estaria com um rapaz no Embauzinho; foram até o local; do lado de fora da casa, visualizou umas plantas que eram vasos de maconha; foi atendido por um dos 3 irmãos; explicou a situação ao irmão, que franqueou a entrada; em vistoria pela residência, acharam vários pinos de cocaína, maconha, crack; a moto não foi encontrada no local; próximo à casa, um dos irmãos foi encontrado (o caçula); levaram até a casa; depois que recolheram toda a droga, foram até a delegacia de Lorena para fazer a apresentação ao delegado de polícia; lá, foram informados que um advogado iria lá e apresentaria um terceiro irmão como proprietário da droga; pouco tempo, apareceu uma advogada e um dos irmãos assumindo toda a droga; a moto ficou de ser apresentada depois; em outra data, no serviço noturno, falaram que a moto estaria no bairro da Várzea Alegre; a moto estava lá e foi recolhida; a moto roubada em Cruzeiro que estaria com um dos irmãos; a moto foi localizada abandonada; havia um pouco de drogas na estante; a maioria das drogas estava dentro dos pés da cama (tubos de madeira); não lembra se o irmão que deixou entrar falou de quem era a cama; só lembra que esse irmão falou que os outros dois irmãos mexiam com coisa errada; o irmão assumiu que havia comprado a moto, sem participar

Em seu interrogatório, o Réu ALESSANDRO TAVARES DOS SANTOS afirmou que: todos os fatos são verdadeiros; a munição foi encontrada tudo junto; praticava o tráfico de drogas sozinho, sem o irmão; pegou as drogas para usar e vender; não chegou a vender nada; a droga foi apreendida no local descrito na denúncia; havia 230 pinos de cocaína, 200g de maconha e crack; comprou a moto no Embauzinho; o meliante ofereceu a moto por R\$300,00; não pensou duas vezes e comprou; não conhecia a

pessoa que vendeu; puxou o número da placa pelo aplicativo para ver se era roubada, mas não tinha restrição; rodou em via pública com a moto; foi nessa busca que a câmera capturou; não estranhou o fato de deixarem a moto com ele por R\$300,00; a moto estava guardada em casa; baixou um aplicativo no "play store" para buscar a placa; o aplicativo só mostrou o modelo e a placa; aparecia o licenciamento, o modelo e o ano; não lembra quem era o proprietário; o IPVA estava pago; quando soube que a moto era furtada, se prontificou a devolver; foi se entregar e assumiu tudo; LUIZ GUSTAVO é usuário;

Em seu interrogatório, o Réu LUIZ GUSTAVO TAVARES DOS SANTOS afirmou que: era dono dos pés de maconha, mas era para consumo; as drogas eram de ALESSANDRO; era só o pé de maconha que era dele; a munição era de ALESSANDRO; não tinha envolvimento com a venda de drogas; as plantas de maconha eram para uso pessoal.

Ao fim da instrução, não é possível concluir que a conduta do Réu desdobrou o previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Nota-se que não há certeza sobre a mercancia nem sobre a adequação da conduta a alguma das outras modalidades previstas no art. 33, caput.

A par dos depoimentos ofertados em juízo observa-se que o réu era usuário de drogas, que o pé de maconha encontrado era o único entorpecente que pertencia a ele (03 vasos, contendo Cannabis Sativa L), sendo esta quantidade indicativa de uso próprio.

Além disso, não foram encontrados outros instrumentos que pudessem afastar a tese defensiva (radiocomunicadores, cadernetas, balanças, embalagens, grande quantidade de dinheiro etc.).

Em situações semelhantes, assim se manifestou o TJSP:

REVISÃO CRIMINAL. Art. 621, I, segunda parte, CPP. Tráfico de Drogas. Condenação pelo caput do art. 33 da Lei 11.343/06, confirmada em sede de apelação.

Desclassificação para o art. 28 da mesma Lei. Possibilidade. Ausência de indícios concretos da mercancia ilícita. Pequena quantidade de drogas. Réu preso na posse de 0,8g de cocaína, na forma de crack, e R\$ 90,00 em dinheiro. Prova policial superficial. Circunstâncias destacadas no voto que são desfavoráveis ao Estado-administração. Reincidência por tráfico que é antiga, com pena já extinta. Diversas condenações pretéritas, de outro turno, pelo art. 28 da Lei 11.343/06. Réu localizado com quantidades ínfimas e processo despojado de dados objetivos que estabelecessem correlação delinquencial com o tráfico ilícito de entorpecentes. Parcial procedência para a descCLASSIFICAÇÃO da imputação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.

(TJSP; Revisão Criminal 0020245-71.2019.8.26.0000; Relator (a): Costabile e Solimene; Órgão Julgador: 1º Grupo de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 31ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/08/2021; Data de Registro: 10/08/2021) (grifos acrescidos)

Assim, desclassifico a imputação e passo a analisar o caso concreto à luz do art. 28 da Lei de Drogas.

A materialidade do crime corresponde à prova de sua existência, em outras palavras, são os elementos que demonstram a ocorrência/existência do delito.

Com efeito, o auto de exibição e apreensão de fls. 17/18 demonstra que foram apreendidas, na posse do Réu 03 dolas de 290gramas.

Anote-se que, conforme conclusões do auto de constatação de substância entorpecente provisória de fls.55/58, bem como o laudo definitivo às fls. 144/147, constatou que são substâncias entorpecentes as matérias apreendidas (art. 50, § 1º, da Lei nº 11.343/06), consistente em massa bruta de 289,6 gramas de TETRAHIDROCANNABINOL (THC).

Trata-se precisamente 272,56 gramas de massa líquida (fls.55/58).

A pequena quantidade de drogas desta natureza apreendida, a ausência de comprovação de qualquer ato de mercancia e os depoimentos ofertados são sinais indicativos de que o entorpecente era destinado a uso próprio, como exposto acima.

Referidas provas demonstram, além de qualquer dúvida razoável, a materialidade do crime de porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas).

Do mesmo modo que a materialidade, a autoria encontra-se devidamente comprovada nos autos, já que o conjunto probatório demonstra além de qualquer dúvida razoável que

o acusado LUIZ GUSTAVO TAVARES DOS SANTOS foi o autor do delito de porte de entorpecente para consumo próprio, conforme demonstrados pelos documentos já mencionados e pela prova oral transcrita acima.

À vista de todos esses elementos, conclui-se que o Réu LUIZ GUSTAVO TAVARES DOS SANTOS, com consciência e vontade, isto é, agindo dolosamente, praticou os fatos descritos na denúncia, conduta esta que se amolda formal e materialmente ao tipo do art. 28 da Lei 11.343/06.

Conforme a teoria da indiciabilidade ou da ratio cognoscendi, acolhida pela doutrina majoritária e pela legislação processual, a tipicidade funciona com um indício da ilicitude, razão pela qual cabe ao réu trazer aos autos ao mesmo a dúvida fundada quanto a presença de uma causa de justificação, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal

No caso sob julgamento, contudo, o réu sequer alegou a existência de causas excludentes da ilicitude.

Assim, sendo a tipicidade indiciária da ilicitude e não havendo causas excludentes desta, configurado está o injusto penal.

Quanto a culpabilidade, esta analisada à luz da teoria normativa pura, de viés finalista, como reprovabilidade do injusto ao autor, composta dos elementos imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, do mesmo modo, inexistem nos autos qualquer elemento que possa afastá-la. Destaco que o Réu sequer suscitou a existência de dirimentes.

Desse modo, tem-se que a culpabilidade está presente, uma vez que o Réu é imputável e dotado de potencial consciência da ilicitude, bem como lhe era exigível conduta diversa.

Assim, comprovadas a materialidade, a autoria, a tipicidade e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do réu LUIZ GUSTAVO TAVARES DOS SANTOS pela prática do crime tipificado no art. 28 da Lei de Drogas.

Dosimetria da pena

Fixadas tais premissas, passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), bem como do critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

Das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: a) Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso em apreço, a culpabilidade é natural à espécie. Posto isso, deixo de valorar negativamente esta circunstância judicial; b) Antecedentes: trata-se de acusado sem antecedentes criminais (conforme entendimento da súmula 444 do STJ), motivo pelo qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; c) Conduta social: não há nos autos elementos suficientes para avaliar a vida do acusado em seu ambiente familiar e social, razão pela qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; d) Personalidade do agente: não há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade do réu, razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente; e) Motivos do crime: os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo e suas circunstâncias não fogem do ordinário; f) Circunstâncias do crime: as circunstâncias em que o crime foi praticado não excedem o que se espera em condições normais; g) Consequências do crime: do mesmo modo as consequências, que são aquelas que se devem ordinariamente esperar do crime em questão; h) Comportamento da vítima: tal circunstância também deverá ser valorada como neutra.

Na aplicação da pena, considerando que se trata de réu primário sem registro de antecedentes criminais, bem como as circunstâncias lhe são favoráveis, fixo a pena consistente em advertência sobre os efeitos da droga, por entendê-la suficiente e adequada ao caso.

II. 2 - DA SITUAÇÃO DO RÉU ALESSANDRO TAVARES DOS SANTOS

II. 2.1 - Do crime de tráfico de drogas.

Cuidam os autos de ação penal pública que visa apurar a suposta prática do crime de tráfico de drogas na modalidade consumada.

Inexistindo questões preliminares e/ou prejudiciais capazes de inviabilizar a análise do mérito da causa, ou mesmo nulidades que possam macular os atos e os processos como um todo, as questões trazidas a juízo merecem um provimento jurisdicional de cunho material.

O tipo objetivo do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

Na situação ora em apreço, consigne-se, desde já, que a despeito das alegações da defesa técnica, as provas constantes dos autos são bastantes a fundamentar um juízo condenatório.

Com efeito, o auto de exibição e apreensão de fls. 17/18 demonstra que foram apreendidas na posse do Réu 231 pinos de Cocaína, totalizando 294 gramas; uma porção granel de 08 gramas; e uma porção granel de 56 gramas; 05 pinos de Cocaína de 10 gramas; 10 lacres de Crack de 4,8 gramas; 3 pedras lacre de 4 gramas e 03 pés lacre de Maconha, totalizando 60 gramas, além de R\$198,00 em espécie, e 03 balanças portáteis, sendo corroboradas e constatadas pelos laudos de constatação provisória às fls. 55/58 e laudo definitivo às fls.144/147.

Referidas provas demonstram, além de qualquer dúvida razoável, a materialidade do crime de tráfico de drogas.

Do mesmo modo que a materialidade, a autoria encontra-se devidamente comprovada nos autos, já que o conjunto probatório demonstra além de qualquer dúvida razoável que o acusado ALESSANDRO TAVARES DOS SANTOS foi o autor do crime de tráfico de drogas narrado na denúncia.

Com efeito, as provas colhidas durante a instrução processual são bastantes a fundamentar um juízo condenatório.

Em primeiro lugar, deve-se destacar que, na ausência de dúvida razoável sobre a parcialidade dos policiais envolvidos na operação, o seu depoimento é um meio idôneo de prova:

Apelação - Furto qualificado tentado - Condenação -Recurso da defesa - Pedido de absolvição por falta de provas e pela incidência do princípio da insignificância - Não acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Prova oral harmônica e coesa - Palavra da vítima goza de especial relevância nos crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade - Depoimento policial constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade - Qualificadora do rompimento de obstáculo comprovada pelas declarações da vítima e, especialmente, pelo laudo pericial - Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância - Ausência de previsão legal - Afronta ao direito fundamental de propriedade - Cabimento do "furto privilegiado", desde que preenchidos os requisitos legais - Pleito de redução da fração de aumento empregada em virtude da agravante da reincidência (de 1/3 para 1/6) - Descabimento - Reincidência específica autoriza incremento maior que 1/6 - Requerimento de aplicação da fração máxima de diminuição cabível pela tentativa (2/3) - Inviabilidade - "Iter criminis" percorrido pelo agente - Proximidade da consumação - Pedidos de modificação do regime inicial semiaberto para o aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Impossibilidade - Reincidência específica - Recurso não provido - Erro material da sentença - Promovida a correção da capitulação jurídica do fato.

(TJSP; Apelação Criminal 0006797-66.2015.8.26.0066; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barretos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/02/2021; Data de Registro: 12/02/2021) (grifos acrescidos)

APELAÇÃO. RECEPÇÃO DOLOSA. Artigo 180, caput, do Código Penal. Sentença condenatória. Preliminar. Alegação de ausência do laudo de exame de corpo de delito. Crime que deixa vestígios. Nulidade não reconhecida. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório. Declarações da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Testemunhos de agentes

policiais. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório. Circunstâncias da investitura na posse da coisa que revela a ciência da origem espúria do bem. Condenação mantida. Dosimetria da pena que, entretanto, comporta reparo. Maus antecedentes descaracterizados. A utilização de condenações pretéritas registradas há mais de quatorze anos em desfavor do condenado contrapõe-se à proposta legislativa que fundamenta o próprio sistema de penas, não se reputando legítima a delonga de um desvalor social superado pelo réu criminalmente reabilitado. Reincidência descaracterizada. Documento que não traz informação acerca do trânsito em julgado da sentença condenatória para a defesa. Pena reduzida ao mínimo legal. Regime inicial de cumprimento abrandado para o aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Restituição de bens e valores apreendidos. Impossibilidade. Objetos que interessam à persecução penal. Incidência dos artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal. Sentença reformada em parte. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500083-83.2019.8.26.0548; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Regional de Vila Mimosa - 2ª Vara; Data do Julgamento: 06/10/2020; Data de Registro: 06/10/2020) (grifos acrescidos)

Os depoimentos colhidos e o interrogatório do réu foram coerentes entre si, convergindo quanto aos seguintes fatos: que o réu praticava a mercancia dos entorpecentes sozinho e que as drogas foram encontradas na posse do réu. Deve-se ressaltar que, diante da multiplicidade de condutas previstas no art. 33, caput, da Lei de Drogas, não é necessária a comprovação cabal da mercancia, bastando que haja prova da adequação da conduta a qualquer um dos verbos previstos no tipo penal:

Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 – Recurso defensivo buscando a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal ou, subsidiariamente, a redução da pena, afastando-se o aumento de pena em razão de condenação sem trânsito em julgado para o réu, e mediante a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante – Apreensão de 8,98g de cocaína, na forma de crack – Réu que negou a prática delitiva – negativa que não prospera – Policiais Militares que esclareceram as circunstâncias da prisão em flagrante do réu, que é a certeza visual do crime, bem como da apreensão das drogas. Relataram que, após informação de que o réu retornaria da cidade de Dracena, onde foi comprar drogas para posterior comercialização no Município de Ouro Verde, deslocaram-se até a Rodoviária e aguardaram o retorno dele. Visualizaram o réu descer do ônibus e ele, ao perceber a presença policial, tentou se desfazer da droga. Realizada a abordagem e indagado, o acusado declarou que a droga destinava-se ao seu consumo próprio. A droga foi localizada, e constataram se tratar de uma porção de crack, que não estava fracionada, e não poderia ser consumida naquele estado, sem antes fracioná-la. Réu que é conhecido pela alcunha 'Boliviano', e pela prática de tráfico de drogas, com prisão anterior pela prática do mesmo delito. Droga apreendida com o réu que renderia entre trinta a quarenta porções de crack – Tráfico de drogas consumado – Desnecessidade de prova da mercancia, diante das diversas condutas previstas no art. 33, da Lei de Drogas – Prova que demonstrou efetivamente a ocorrência de tráfico de entorpecentes – condenação de rigor, nos termos da denúncia. Dosimetria – Pena-base fundamentadamente exasperada – Sem alteração na segunda e terceira fases. Não cabimento do redutor de pena, por falta de amparo legal Não cabimento de penas restritivas de direitos, por falta de amparo legal Regime inicial fechado mantido, eis que justificado e por ser o mais adequado no caso concreto. Recurso da Defesa improvido.

(TJSP; Apelação Criminal 0001325-64.2018.8.26.0168; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dracena - 3ª Vara; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro: 26/04/2019) (grifos acrescidos)

À vista de todos esses elementos, conclui-se que o Réu ALESSANDRO TAVARES DOS SANTOS, com consciência e vontade, isto é, agindo dolosamente, praticou os fatos descritos na denúncia, conduta esta que se amolda formal e materialmente ao tipo do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Conforme a teoria da indiciabilidade ou da ratio cognoscendi, acolhida pela doutrina majoritária e pela legislação processual, a tipicidade funciona com um indício da ilicitude, razão pela qual cabe ao réu trazer aos autos ao mesmo a dúvida fundada quanto a presença de uma causa de justificação, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

No caso sob julgamento, contudo, o réu sequer alegou a existência de causas excludentes da ilicitude.

Assim, sendo a tipicidade indiciária da ilicitude e não havendo causas excludentes desta, configurado está o injusto penal.

Quanto a culpabilidade, esta analisada à luz da teoria normativa pura, de viés finalista, como reprovabilidade do injusto ao autor, composta dos elementos imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, do mesmo modo, inexistem nos autos qualquer elemento que possa afastá-la. Destaco que o Réu sequer suscitou a existência de dirimentes.

Desse modo, tem-se que a culpabilidade está presente, uma vez que o Réu é imputável e dotado de potencial consciência da ilicitude, bem como lhe era exigível conduta diversa.

Assim, comprovadas a materialidade, a autoria, a tipicidade e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do réu ALESSANDRO TAVARES DOS SANTOS pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Dosimetria da pena

Das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/06: a) Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso em apreço, é inerente ao tipo penal; b) Antecedentes: tratam-se de acusados sem antecedentes criminais na forma da Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não poderá ser considerada negativa; c) Conduta social: não há nos autos elementos suficientes para avaliar a vida dos acusados em seu ambiente familiar e social, razão pela qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; d) Personalidade do agente: não há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade dos réus, razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente; e) Motivos do crime: os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo e suas circunstâncias não fogem do ordinário; f) Circunstâncias do crime: as circunstâncias em que o crime foi praticado não excedem o que se espera em condições normais; g) Consequências do crime: do mesmo modo as consequências, que são aquelas que se devem ordinariamente esperar do crime em questão; h) Comportamento da vítima: trata-se de crime sem vítima determinada, motivo pelo qual tal circunstância será valorada como neutra; i) Natureza e a quantidade da droga: visando não incidir em bis in idem serão valoradas apenas na terceira fase da dosimetria.

Assim, aumento 1/8 do intervalo da pena abstrata e fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Não há agravantes a reconhecer.

Com relação às atenuantes, é possível reconhecer a da confissão, mas a pena base não pode ficar aquém do mínimo legal. Assim, fixo a pena intermediária em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Quanto à terceira-fase, é preciso enfrentar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, que exige a presença de quatro requisitos para a diminuição da pena: a) primariedade do agente; b) bons antecedentes; c) ausência de dedicação a atividades criminosas; d) não integração de organização criminosa.

Em sede de julgamentos de recursos especiais repetitivos (Tema 1139), o STJ fixou tese no sentido de que "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06."

Desta forma, só é possível afastar a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas se: a) houver maus antecedentes, inclusive por fato anterior à presente imputação, mas com trânsito em julgado posterior ao presente processo; b) houver reincidência; ou c) as circunstâncias do caso concreto (não outros processos) indicarem que não se trata de uma conduta pontual ou iniciante e que há efetiva dedicação a atividades criminosas ou pertencimento a organização criminosa. No caso concreto, não há prova de nenhuma das hipóteses acima, de sorte que entendo que é possível a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Com relação à fração de diminuição, já que o dispositivo prevê uma margem de 1/6 a 2/3, a doutrina sugere a utilização dos critérios do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas:

"91-C. Critérios para a diminuição da pena: o legislador não estipulou quais seriam, apenas mencionando dever o magistrado reduzir a pena de um sexto a dois terços. Cremos que, como sempre, deve o julgador pautar-se pelos elementos do art. 59 do Código Penal, com a especial atenção lançada pelo art. 42 desta Lei: 'o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente'" (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, vol. 1, p. 424) (grifos acrescentados)

Considerando a apreensão de droga da espécie crack e cocaína e em quantidade expressiva, sobretudo se considerada a traficância ordinária da região, a pena intermediária deve ser diminuída na fração de 1/6, razão pela qual fixo a pena definitiva em 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa.

II. 2.2 - Do crime de receptação.

A materialidade do crime corresponde à prova de sua existência, em outras palavras, são os elementos que demonstram a ocorrência/existência do delito.

Na situação sob julgamento, a materialidade delitiva da receptação qualificada restou devidamente comprovada através dos seguintes elementos: boletim de ocorrência (fls. 08/12), bem como nos demais elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Do mesmo modo que a materialidade, a autoria encontra-se devidamente comprovada nos autos, já que o conjunto probatório demonstra além de qualquer dúvida razoável que o acusado ALESSANDRO TAVARES DOS SANTOS foi o autor do crime de receptação, uma vez que: os relatos dos policiais e do próprio réu convergem no sentido de que a moto subtraída estava na posse do acusado, este afirmando que adquiriu no valor de R\$ 300,00, sem qualquer documentação.

Anote-se, outrossim, que não merece acolhimento a alegação do réu no sentido de que não sabia a origem criminosa do bem, que consultou a placa por aplicativo e não encontrou nenhuma restrição já que os elementos acima mencionados apontam no sentido contrário, uma vez que pelo valor que se adquiriu o bem pressupõe a ilicitude do objeto.

Ressalte-se que nada existe de concreto nos autos a indicar que a vítima ou as testemunhas ouvidas em juízo estivessem tentando incriminar falsamente o réu, atribuindo-lhe o falso cometimento de um delito.

Nesse cenário, das provas constantes dos autos, se extrai que o réu de fato, adquiriu coisa objeto de crime anterior, precisamente uma motocicleta.

É preciso destacar que, segundo o STJ, havendo a apreensão do bem objeto de crime em poder do acusado, cabe à defesa o ônus de comprovar a sua origem lícita ou a sua conduta culposa (art. 180, §3º):

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Para rever o entendimento firmado pela Corte de origem, no sentido de absolver o agravante por insuficiência de provas do delito de receptação, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/3/2018).

3. No que tange ao pleito referente à inidoneidade da fundamentação empregada para valoração negativa da conduta social, a tese não foi objeto de debate e discussão na instância ordinária, carecendo do adequado e indispensável prequestionamento, motivo pelo qual incidentes, por analogia, as Súmulas ns. 282 e 356, ambas do STF.

4. A jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que a presença da circunstância negativa veda a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, de acordo com o disposto no art. 44 do Código Penal (AgRg no AREsp 1925219/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 2/3/2022).

5. Agravo re gimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.919.030/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.) (grifos acrescidos)

À vista de todos esses elementos, conclui-se que o Réu, com consciência e vontade, isto é, agindo dolosamente, praticou os fatos descritos na denúncia, conduta esta que se amolda formal e materialmente ao tipo art. 180, caput, do Código Penal. Conforme a teoria da indiciabilidade ou da ratio cognoscendi, acolhida pela doutrina majoritária e pela legislação processual, a tipicidade funciona com um indício da ilicitude, razão pela qual cabe ao réu trazer aos autos ao mesmo a dúvida fundada quanto a presença de uma causa de justificação, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

No caso sob julgamento, contudo, o réu sequer alegou a existência de causas excludentes da ilicitude.

Assim, sendo a tipicidade indiciária da ilicitude e não havendo causas excludentes desta, configurado está o injusto penal.

Quanto à culpabilidade, esta analisada à luz da teoria normativa pura, de viés finalista, como reprovabilidade do injusto ao autor, composta dos elementos imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, do mesmo modo, inexistem nos autos qualquer elemento que possa afastá-la. Destaco que o réu sequer suscitou a existência de dirimentes.

Desse modo, tem-se que a culpabilidade está presente, uma vez que o réu é imputável e dotado de potencial consciência da ilicitude, bem como lhe era exigível conduta diversa.

Assim, comprovadas a materialidade, a autoria, a tipicidade e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do réu ALESSANDRO TAVARES DOS SANTOS pela prática do crime tipificado no art. 180, caput, do CP.

Da dosimetria da pena

Fixadas tais premissas, passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), bem como do critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

Das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: a) Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso em apreço, a culpabilidade é natural à espécie. Posto isso, deixo de valorar negativamente esta circunstância judicial; b) Antecedentes: trata-se de acusado sem antecedentes criminais (conforme entendimento da súmula 444 do STJ), motivo pelo qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; c) Conduta social: não há nos autos elementos suficientes para

avaliar a vida do acusado em seu ambiente familiar e social, razão pela qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; d) Personalidade do agente: não há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade do réu, razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente; e) Motivos do crime: os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo e suas circunstâncias não fogem do ordinário; f) Circunstâncias do crime: as circunstâncias em que o crime foi praticado não excedem o que se espera em condições normais; g) Consequências do crime: do mesmo modo as consequências, que são aquelas que se devem ordinariamente esperar do crime em questão; h) Comportamento da vítima: tal circunstância também deverá ser valorada como neutra.

Diante de tais circunstâncias, fixo a pena-base em 1 ano de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes a reconhecer, razão pela qual mantenho a pena-intermediária em 1 ano de reclusão e 10 dias multa. Não há causas de aumento nem de diminuição a reconhecer, razão pela qual a pena definitiva fica em 1 ano de reclusão e 10 dias multa.

Em atendimento ao disposto no art. 49, §1º, do Código Penal, fixo valor do dia-multa em 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, pois não há nos autos informações sobre a condição financeira do réu.

Do concurso material e do regime inicial para cumprimento da pena

O caso concreto envolve concurso material, de sorte que as penas devem ser aplicadas cumulativamente e somadas para fins de determinação do regime inicial do cumprimento de pena, nos termos do art. 69 do CP.

Ressalte-se que não há que se falar em consunção, já que os crimes se consomem em momentos diversos, tutelam bens jurídicos diferentes, não há relação de crime-meio e crime-fim nem vínculo necessário entre a consumação dos dois delitos:

- Embargos de declaração - Alegação de omissão na análise da tese de consunção entre as condutas de receptação e uso de documento falso, bem como afastamento da reincidência. - Afastada a tese de consunção, eis que o uso de documento falso (CRLV) e a receptação do veículo são crimes autônomos que tutelam bens jurídicos diversos: fé pública e Inviolabilidade patrimonial, respectivamente. Não há que se falar em crime meio ou crime fim em relação às condutas do embargante. - Manutenção da agravante reincidência e, por consequência, o regime intermediário. - Embargos de declaração acolhidos para declarar o afastamento da tese de consunção e manutenção do regime semiaberto.

(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0003305-57.2011.8.26.0082; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Boituva - 1ª Vara; Data do Julgamento: 27/04/2021; Data de Registro: 27/04/2021) (grifos acrescidos)

Nos termos dos art. 33, §§2º e 3º do Código Penal, e levando em consideração a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma legal, fixo o regime Nos termos dos art. 33, §§2º e 3º do Código Penal, e levando em consideração a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma legal, fixo o regime SEMI-ABERTO para o início do cumprimento da pena.

A quantidade de pena inviabiliza a substituição por pena restritiva de direitos (art. 44, I) e a suspensão condicional da pena (art. 77).

II. 3- Do crime do art.35 da lei nº 11.343/06.

O art. 35 da Lei de Drogas tipifica a conduta de “associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei”.

O entendimento consolidado no STJ é o de que a incidência desse tipo penal exige certa estabilidade e permanência:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. REGIME

SEMIABERTO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.
2. No caso, as instâncias ordinárias, em nenhum momento, fizeram referência ao vínculo associativo estável e permanente porventura existente entre os pacientes e os integrantes da facção criminosa conhecida como Comando Vermelho; na verdade, as instâncias de origem presumiram, com base apenas no local em que os réus foram presos em flagrante, que eles seriam integrantes do Comando Vermelho e, assim, proclamaram a condenação destes com base em meras conjecturas acerca de uma *societas sceleris*.
3. Ao funcionar como regra que disciplina a atividade probatória, a presunção de não culpabilidade preserva a liberdade e a inocência do acusado contra juízos baseados em mera probabilidade, determinando que somente a certeza pode lastrear uma condenação. A presunção de inocência, sob tal perspectiva, impõe ao titular da ação penal todo o ônus de provar a acusação, quer a parte *objecti*, quer a parte *subjecti*. Não basta, portanto, atribuir a alguém conduta cuja compreensão e subsunção jurídico-normativa, em sua dinâmica subjetiva ? o ânimo a mover a conduta ?, decorre de avaliação pessoal de agentes do Estado, e não dos fatos e das circunstâncias objetivamente demonstradas.
4. Uma vez afastada a condenação dos pacientes pelo crime de associação ao tráfico e porque eles são tecnicamente primários, possuidores de bons antecedentes e não há, nos autos, elementos concretos a evidenciar sua dedicação a atividades delituosas ou integração a organização criminosa, deve ser aplicada, em favor, dos dois a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
5. Como consectário da redução efetivada na pena dos acusados, deve ser feito o ajuste no regime inicial do seu cumprimento das respectivas penalidades para o semiaberto, pois, apesar de terem sido condenados a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, serem tecnicamente primários ao tempo do delito e, possuidores de bons antecedentes, tiveram a pena-base estabelecida acima do mínimo legal.
6. Ordem concedida, para absolver os pacientes pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, reconhecer a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e aplicá-la no patamar máximo de 2/3.
(HC 596.389/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 30/11/2021) (grifos acrescidos)

Por isso, não é suficiente que o tráfico de drogas seja realizado em concurso de pessoas:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO: INVIABILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO EVIDENCIADAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, COM BASE EM CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)
2. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário

o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário" (HC n. 434.972/RJ, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1º/8/2018).

4. No caso concreto, as instâncias ordinárias concluíram pela existência de ânimo associativo entre o paciente e os corréus, evidenciado sobretudo pela troca de mensagens detectada nos aparelhos celulares dos corréus que mencionavam o nome do paciente e que descreviam a divisão de tarefas entre eles, de maneira organizada, estável e duradoura, com o fito de traficar entorpecentes (maconha, cocaína e crack).

5. A despeito de não ter sido apreendido o celular do paciente para confronto com as mensagens transcritas dos celulares dos outros dois corréus, é possível concluir que o contato ali designado como "Doni RD" correspondia ao número do celular do paciente seja diante da afirmação feita pela corré, em sede inquisitorial, de que o paciente vendia drogas para seu namorado (o outro corréu), seja diante dos testemunhos dos policiais que, em juízo, asseveraram que teria sido a mencionada corré quem os informou que o paciente, seu vizinho, lhes vendia a droga e também a armazenava.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 693.319/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021) (grifos acrescidos)

É esse também o entendimento do TJSP:

APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM.

Pretensão de reforma, quanto a cada um dos ilícitos, e substituição da reprimenda.

Parcial possibilidade. 1. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade demonstradas.

Depoimento dos policiais. Meio seguro de prova. Precedentes. 2. Associação para o

tráfico. Dolo associativo não demonstrado. Concurso de pessoas, eventual ou

permanente, que não se confunde com a figura do art. 35 da Lei n. 11.343/06.

Precedentes. Sentença alterada, neste ponto. Improcedência da representação. 3.

Internação. Cabimento. Interpretação extensiva das hipóteses anotadas no art. 122

do ECA. Gravidade da conduta. Condições pessoais desfavoráveis. Necessidade de

afastamento do meio deletério. Proposta socioeducativa intensificada. Atendimento

do critério da excepcionalidade (art. 122, § 2º, do ECA). Precedentes. Sentença

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1515532-05.2020.8.26.0562; Relator (a): Sulaiman Miguel;

Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Santos - Vara da Infância, Juventude e do

Idoso; Data do Julgamento: 04/10/2021; Data de Registro: 04/10/2021) (grifos

acrescidos)

Apelação. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Sentença

condenatória. Recursos das defesas. PRELIMINARES. 1. Violação ao princípio do

promotor natural não configurada. O princípio do promotor natural proíbe a

designação casuística de um promotor, para determinado caso, pela chefia da

Instituição, criando a figura do promotor de exceção. Situação não configurada. 2.

O artigo 385, do Código de Processo Penal é expresso no sentido de que o juiz, nos

casos de ação penal pública, pode proferir sentença condenatória